

次の1から5までの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙が丙の住居及び丁の住居に侵入することを決意しているのを知り、乙に対し、侵入用具としてドライバー1本を貸与し、その翌日、乙はこれを利用して丙の住居及び丁の住居にそれぞれ侵入した。甲には、2個の住居侵入罪の従犯が成立し、両罪は観念的競合となる。
2. 甲は、乙方から絵画を盗み、自宅に持ち帰ったが、その後売却先が見付からなかったため、その絵画を破り捨てた。甲には、窃盗罪と器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。
3. 甲は、自己が経営する店において、1週間のうちに、同店を訪れた複数の客に対し、いずれも同じ題名・内容のわいせつ図画に該当するDVDを数回にわたって販売した。甲には、わいせつ物頒布等罪の一罪が成立する。(改)
4. 甲は、自己の運転する自動車を脇見運転により通行人乙に衝突させて同人を死亡させた上、慌ててその場から逃走しようとして安全確認を怠って自車をUターンさせたため、折から対向車線を走行してきた丙運転の自動車に自車を衝突させて同人に傷害を負わせた。甲には、過失運転致死罪と過失運転傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
5. 甲は、郵便局の窓口で、偽造された郵便貯金払戻請求書1通を、不正に入手した他人名義の貯金通帳とともに郵便局員乙に提出して貯金の払戻しを請求し、これを正当な払戻請求と誤信した乙から貯金の払戻しを受けた。甲には、詐欺罪の一罪のみが成立する。

*平成25年11月27日法律第86号により、自動車運転過失致死傷罪は、旧刑法211条2項から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に移され、罪名も過失運転致死傷罪に改められた。そのため、記述4については改題をした。

№189	罪 数	正答率
H22-16	正 解 1、3 (順不同)	63%

1 正しい

本記述では、1個の幫助行為に対して正犯が2個の犯罪を実行した場合に、幫助犯(62条1項)に成立する犯罪の個数及び罪数処理が問題となる。幫助犯に成立する犯罪の個数に関し、判例は、ある者が、正犯から渡された現金を銀行保証小切手に替えて正犯に交付することによって、正犯が行った2個の覚せい剤取締法違反行為を幫助したという事案において、「成立すべき幫助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定される」としている(最決昭57.2.17、百選I107事件)。その理由として、判例は、「幫助罪は正犯の犯行を幫助することによって成立するものである」ということを挙げている。さらに、同判例は、幫助罪が数個成立する場合に、観念的競合の関係となるか否かについて、「幫助行為それ自体についてこれをみるべきである。」としている。その理由として、「幫助犯における行為は幫助犯のした幫助行為そのものにほかならない」ということを挙げている。本記述で、正犯である乙には丙、丁それぞれに対する2つの住居侵入罪(130条前段)が成立するため、乙を幫助した甲には住居侵入罪の幫助犯が二罪成立することになる。そして、甲の幫助行為は、ドライバーを1本貸与したという1個の行為であるから、甲に成立する2つの住居侵入罪の幫助犯は、観念的競合の関係になる。

2 誤っている

窃盗犯(235条)が財物を毀損した場合に、毀損行為について器物損壊罪(261条)が成立するかが問題となる。この点、窃盗犯が財物を毀損しても、器物損壊罪は成立しないと解されている。なぜなら、窃盗犯は状態犯であり、犯罪終了後の侵害状態はそれ以前の犯罪に評価し尽くされているからである(不可罰的事後行為)。

3 正しい

大判昭10.11.11。本記述では、わいせつ物頒布等罪(175条1項)の罪数が問題となる。この点、同一人に複数回わいせつ図画を販売した事案において、判例は、わいせつ物頒布等罪は性質上反復される多数行為を含むものであるから、複数回の販売行為について包括してわいせつ物頒布等罪一罪が成立するとしている。本記述のように、数人に対してわいせつ物を販売する場合にも、反復される多数行為は構成要件の行為として予定されているから、包括一罪となる。

4 誤っている

54条1項前段の「1個の行為」の意義が問題となる。判例は、「1個の行為」について、「法的評価をはなれ構成要件の観点から捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合をいう」としている(最大判昭49.5.29、百選I104事件)。本記述の事案では、脇見運転による衝突行為と、その後逃走しようと安全確認を怠ってUターンをしたことによる衝突行為は、異なる原因によるものであり、社会的見解上1個のものとは評価されない。したがって、本記述は、甲には過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)と過失運転傷害罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)とが成立し、両罪は併合罪となるとすべきところを、観念的競合となるとしている点で、誤っている。

5 誤っている

大判明 44.11.10。本記述では、偽造文書の行使によって詐欺をした場合に、詐欺罪（246条1項）とは別に偽造私文書行使罪（161条）が成立するかが問題となる。この点、虚偽の記載のある公文書を用いて詐欺罪を犯した事案において、判例は、54条1項の「手段である行為」とは、犯罪の性質上普通その実行の方法として用いられるべき行為であって、かつ、その犯罪の構成要件とならないものをいうとした上で、偽造又は虚偽の事項が記載された文書を行使して財物を騙取した場合において、行使の行為は、詐欺罪の構成要件である欺罔の手段に過ぎず、欺罔そのものではないので、詐欺罪の行使要件となるものではなく、行使行為は詐欺罪の実行方法として普通用いられるものに属する行為であるから詐欺罪の手段であるとして、偽造公文書行使罪と詐欺罪を成立させて、両罪が牽連犯（54条1項後段）になるとしている。